

1500553-33.2019.8.26.0187

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... o que autoriza a aplicação da cláusula de 'tráfico privilegiado'.

No ponto, destaque-se, especificamente, não existem indícios suficientes de que integre organização criminosa ou se dedique de maneira 'profissional', permanente e reiterada ao tráfico - situação a qual, por evidente, não descaracteriza o tráfico, mas, certamente, implica em diferenças, em relação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Centro - CEP 18870-000, Fone: (14) 3382-1855,

Fartura-SP - E-mail: fartura@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500553-33.2019.8.26.0187

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência

- 2277156/2019 - DEL.POL.FARTURA, 7570392 - DEL.POL.FARTURA, 864/19/120 -

DEL.POL.FARTURA, 2277156 - DEL.POL.FARTURA, 864/19/120 - DEL.POL.FARTURA, 2277156 -

DEL.POL.FARTURA, 864/19/120 - DEL.POL.FARTURA, 2277156 - DEL.POL.FARTURA,

864/19/120 - DEL.POL.FARTURA, 2277156 - DEL.POL.FARTURA, 864/19/120 -

DEL.POL.FARTURA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSIMARA IZABEL DE SIQUEIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

23/03/2022

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, nesta cidade e Comarca de Fartura, Estado de São Paulo, na sala virtual de audiência, presente o MM. Juiz Substituto desta Comarca, Exmo. Sr. Dr. Mário Henrique Gebran Schirmer, comigo Escrevente Técnico Judiciário, no final nomeado e assinado, aí, após os pregões legais, verificou-se o comparecimento do DD. Promotor de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Pedro Rafael Nogueira Guimarães, do ré Rosimara Izabel de Siqueira, acompanhada de seu defensor Dr. Adriano José Moreira de Melo, e das testemunhas comuns Paulo

César de Souza, Walter José Nobile e Rute Pereira Diniz. Ausente a testemunha comum Israel Pereira Diniz, intimada às fls. 214. Instalada a audiência, pelo DD. Juiz foram inquiridas as testemunhas Paulo Cesar de Souza e Walter José Nobile, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Na sequência, pelo DD. Juiz foi ouvida, na qualidade de informante, Rute Pereira Diniz, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. A seguir, pelo Dr. Promotor foi feita a seguinte manifestação: "MM. Juiz, desisto do depoimento da testemunha Israel Pereira Diniz". Dada a palavra ao defensor da ré, por ele foi feita a seguinte manifestação: "MM. Juiz, desisto, igualmente, do depoimento da testemunha Israel." A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte deliberação: "Homologo a desistência da testemunha comum." Após, a ré foi interrogada, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Em seguida, pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e perguntado às partes se havia algum requerimento de diligências, nos termos do artigo 402 do CPP, sendo que não houve qualquer requerimento, passando-se então aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi feita a seguinte manifestação, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. A seguir, foi dada a palavra ao(a) Dr(a). Defensor(a) do réu, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Posteriormente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ROSIMARA IZABEL DE SIQUEIRA, já qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06. A denúncia foi apresentada nos seguintes termos: "Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de setembro de 2019, por volta das 9 horas, na residência situada na Rua Emílio Del Cistia, 183, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Fartura/SP, ROSIMARA IZABEL DE SIQUEIRA, qualificada em fls. 7/8, guardou 1 (um) tijolo de "maconha", pesando aproximadamente 65,9 g (sessenta e cinco gramas e nove miligramas), que era destinada a entrega em outra Unidade da Federação, conforme boletim de ocorrência de fls. 10/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/15, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 16 e laudo toxicológico de fls. 52/57, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, a denunciada era casada Israel Pereira Diniz, que é usuário de drogas e morava na cidade de Foz do Iguaçu/PR. A denunciada comprou a substância entorpecente acima e inseriu dentro de um aparelho de televisão de 14 (quatorze) polegadas, que ficou guardado na casa da

testemunha Rute Pereira Diniz, que é irmã de Israel Pereira Diniz. A referida testemunha levaria o aparelho televisor para Israel Pereira Diniz quando visitasse o irmão na cidade de Foz do Iguaçu/PR. O fato foi descoberto porque a testemunha abriu a televisão e viu a substância entorpecente, que foi apreendida pela polícia civil. A perícia evidenciou a presença do hidrocannabinol, responsável pelos principais efeitos farmacológicos da maconha, conforme laudo pericial de fls. 52/5. Pelas circunstâncias dos fatos, quantidade de substância entorpecente apreendida, que estava oculta em um aparelho televisor e seria transportado para outro Estado, tudo em conjunto, comprova a prática do tráfico ilícito de drogas caracterizado entre Estados da Federação." (fls. 138-139).

A prisão em flagrante foi homologação e concedida liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão (fls. 35-38).

A acusada apresentou defesa prévia (fl. 161).

A denúncia foi recebida na data de 20 de outubro de 2021, não se concedendo absolvição sumária e sendo determinada a realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 166-169).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas e a inquirição da acusada, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020.

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pela procedência da demanda. Argumentou que presente a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, uma vez que a transposição de fronteira não se faz necessária. Alegou que possível o reconhecimento da cláusula do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, aplicável a atenuante de confissão espontânea, possível a fixação de regime inicial aberto e a substituição de pena na forma do art. 44, do CP.

A Defesa da acusada pleiteou a sua absolvição, sustentando a insuficiência do conjunto probatório, especificamente argumentando inexistir prova de autoria e materialidade. Subsidiariamente, postulou pela impossibilidade de aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, sustentando que a substância nem ao menos saiu da cidade de origem.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inexistem alegações a respeito do trâmite processual e, tampouco, há, neste contexto, matéria a se conhecer de ofício, dado que o feito transcorreu regularmente.

Por esta razão, é possível o julgamento do mérito da pretensão punitiva.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. *Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política*. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. *Sobre a Violência*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência dos fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. *Ônus da prova no processo penal*. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do conjunto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro

probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática do delito imputado à ré.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade e a autoria restam demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição (fls. 12-15), auto de constatação preliminar (fl. 16), laudos periciais (fls. 54-57), bem como pela prova oral produzida em juízo.

4. A autoria está também demonstrada, pesando em desfavor do acusado, sobretudo pelos depoimentos apresentados em juízo e em fase policial.

Nesse contexto, a testemunha Paulo César (investigador de polícia) relatou, em síntese, que a Sra. Rute, cunhada de Rosimari, chamou a polícia, dizendo que gostaria que os policiais fossem a sua casa para conversar. Em sua residência, a Sra. Rute mostrou um saco plástico com uma porção de maconha. Disse que encontrou a porção de maconha dentro de um televisor, que teria sido entregue a Rute por Rosimara para que levasse ao seu marido, em Foz de Iguaçu. Ao conversarem com a acusada, ela confirmou que teria comprado a droga e estava encaminhando ao acusado, em Foz do Iguaçu.

A testemunha Walter (investigador de polícia) disse, em síntese, que Sra. Rute, cunhada da ré, entrou em contato, pedindo para que fossem conversar com ela em sua casa. No local, Rute disse que estava com uma viagem marcada a Foz do Iguaçu para que visitar seu irmão, Israel (marido de Rosimara), tendo recebido alguns bens da acusada para levar. Porém, poucos dias antes da viagem, a Sra. Rute foi informada por Israel (seu irmão, esposo da acusada e pessoa que 'encomendou' a droga) para que olhasse dentro do televisor se havia algo de ilícito. Então, a Sra. Rute descobriu a porção de droga e chamou a polícia.

A informante Rute (ex-cunhada da acusada) narrou, em síntese, que estava com uma viagem marcada para Foz de Iguaçu, para visitar seu irmão, que estava lá a trabalho. Então, a acusada mandou alguns objetos para que levasse ao irmão da depoente (marido da acusada). Entre estes objetos estava uma televisão. Porém, pouco antes da viagem, Israel (seu irmão, esposo da acusada e pessoa que 'encomendou' a droga) entrou em contato com a depoente para que verificasse a televisão e, então, encontrou a droga.

Em seu interrogatório, a acusada confessou a prática delitiva. Disse que estava mandando a droga a pedido de Israel. Afirmou que seu marido pediu para que ela comprasse a droga e lhe enviasse. Relatou que não iria usar as drogas, nunca tendo usado entorpecentes. Afirmou que brigou com o acusado um dia antes, porque ele teria lhe traído. Nesta discussão, disse que iria passar a informação à polícia a respeito da droga. Por este motivo, o Sr. Israel antecipou-se e informou à Rute a respeito da droga que estava escondida no televisor.

5. Diante deste contexto, autoria e materialidade estão, de maneira geral, comprovadas, conforme passo expor adiante.

No ponto, resalto, em primeiro lugar, que os policiais narram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa a acusada. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento do fato, imprimindo certeza e seriedade em sua narrativa.

Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico aos de outras pessoas que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,

por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

"3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

Nesse cenário, observe-se que os relatos confirmaram a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória. Isto porque a narrativa apresentada pelas testemunhas é robusta, harmônica e verossímil, encontrando respaldo nas demais provas dos autos, em especial os laudos periciais e auto de apreensão das drogas. Ademais, a própria acusada confirmou que, realmente, pretendia que a droga fosse entregue a seu marido, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.

Dessa maneira, entendo que estão comprovadas autoria e materialidade da conduta descrita na exordial.

6. Por esta razão, passa à análise do tipo penal.

6.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: "Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". (grifo nosso).

In casu, a conduta da agente se ajusta aos verbos descritos no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que as provas dos autos demonstram, de maneira segura, que o acusado tinha em sua residência ("ter em depósito", "guardar", "fornecer" e "transportar") as drogas apreendidas nos autos.

6.2. Aplicável, ainda, a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, uma vez que demonstrado que a droga se destinava a outro estado da federação, dado que, conforme apresentado nos depoimentos, seria encaminhada para o consumo do esposo da acusada na cidade de Foz do Iguaçu/PR.

No ponto, destaco que, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, não se faz imprescindível a transposição da fronteira para a caracterização da causa de aumento. Ademais, a respeito da tese arguida pela defesa, note-se que os atos preparatórios inerentes à causa de aumentos tinham sido iniciados (esconder a droga na televisão) e, por si, são também crimes, haja vista o delito plurinuclear do art. 33, da Lei de Drogas.

6.3. Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, entendo ser cabível, dado que a acusada é primária (fls. 207-208) - nunca tendo respondido por qualquer outro fato -, não ficou comprovado que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, o que autoriza a aplicação da cláusula de 'tráfico privilegiado'.

No ponto, destaque-se, especificamente, não existem indícios suficientes de que integre organização criminosa ou se dedique de maneira 'profissional', permanente e

reiterada ao tráfico – situação a qual, por evidente, não descaracteriza o tráfico, mas, certamente, implica em diferenças, em relação aqueles que fazem do comércio ilegal de entorpecentes seu 'meio de vida'.

Destaque-se que inexistente qualquer impedimento normativo a possibilidade de aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, juntamente com algumas das causas de aumento do art. 40, do mesmo diploma. Ademais, além da inexistência de impedimento normativo, não se verifica, no caso em análise, qualquer obstáculo fático à aplicação conjunta de ambos os dispositivos.

6.4. Ainda sobre a tipicidade, improcedente a tese de desclassificação, ao art. 28 ou art. 33, §3º, ambos da Lei de Drogas, uma vez que a própria acusada negou que faria uso da substância.

Portanto, ainda que de maneira peculiar, o fato é que a acusada praticou o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

7. A respeito dos demais elementos dos injustos penais, observa-se que a acusada é imputável, tem a consciência da ilicitude de suas ações, lhe era exigível conduta diversa e não agia amparado por causa excludente de ilicitude, devendo, então, responder pelas ações praticadas, dado que todos os elementos da estrutura analítica dos delitos estão presentes.

É evidente que, no caso, a maior reprovabilidade recai sobre as ações de Israel.

Afinal, foi ele quem encomendou as drogas, pediu para que sua esposa (acusada) lhe encaminhasse os entorpecentes e, posteriormente, informou a respeito do ilícito.

Porém, ainda que a situação provoque grave repulsa moral – e, porventura, jurídica – em relação ao comportamento de Israel, tal peculiaridade não tem o condão de descaracterizar a ilicitude ou culpabilidade das ações da acusada.

8. Ante o exposto, restou claramente demonstrado que a acusada ROSIMARA IZABEL DE SIQUEIRA realizou a conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal indicado no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

9. Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06 apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

9.1. Na análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não foi possível valorar a conduta social e o comportamento da vítima, a personalidade da agente, em razão da ausência de elementos informativos a respeito de tais vetores. Ainda, os motivos e as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. A culpabilidade é neutra, na medida em que as circunstâncias inerentes ao caso em análise são comuns à espécie. O acusado é primário (fls. 207-208).

Em relação ao crime de “tráfico de drogas”, o art. 42 da Lei 11.343/06, estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas. In casu, a quantidade de drogas, não deve ser sopesada nessa etapa, mesmo que a quantidade não seja desprezível, essa se encontra consonância com os padrões ordinários verificados na prática. Igualmente, inexistente razão à valoração negativa da natureza do entorpecente. Embora inequivocamente trata-se de substância ilícita, em vista das experiências e padrões judiciais e sociais, não existem motivos à valoração da natureza da droga.

Desta maneira, conforme o exposto acima exaspero a pena base, de modo que fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

9.2. Passo à segunda fase da dosimetria. Neste momento, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes. Nesta fase, não se verifica a presença de nenhuma circunstância agravante. Há presente a atenuante de confissão espontânea, na forma do art. 65, III, d, do CP, uma vez que a acusada confirmou que realmente pretendia realizar o delito de tráfico de drogas. Porém, considerando que a pena base foi fixada no mínimo legal e em vista do sistema de dosimetria da pena, previsto no art. 68, do CP, e da Súmula 231, do STJ, impossível que a reprimenda seja fixada aquém do mínimo legal nesta fase.

Desta forma, a pena intermediária se mantém no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

9.3. Na terceira fase da dosimetria analisam-se as causas de aumento e diminuição.

In casu, está presente a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, na medida em que comprovado, conforme exposto acima, que a droga se dirigia a outro Estado da federação (Paraná). A respeito o quantum de aumento, considerando a pequena quantidade apreendida e o fato de que a droga, embora se destinasse a outro Estado, nem ao menos chegou a sair desta cidade, o aumento deve ser em patamar mínimo 1/6 (um sexto): 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em contrapartida, conforme exposto acima, devida a aplicação da norma disposta no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que a acusada é primária e não ficou suficientemente demonstrado que se dedique de maneira permanente às atividades ilícitas ou integre organização criminosa. No ponto, considerando as peculiaridades do caso (acusada primária, droga se destinava a seu marido a pedido dele e pequena quantidade de maconha), possível a redução de pena em patamar máximo - isto é, 2/3 (dois terços).

Por esta razão, a pena definitiva fica em: 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

9.4. Tendo em vista o quantum de pena aplicado e a primariedade do agente, nos termos do art. 33, §2º, do CP, fixo o regime ABERTO para o início de cumprimento de pena.

Fixa-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, nos termos da tabela do TJ-SP, uma vez que não há nos autos informações que permitam arbitramento em outro valor.

9.5. A despeito da redação do art. 44, da Lei de Drogas, adotando entendimento consolidado nos tribunais superiores, entendo possível a substituição de pena no caso em análise, em razão do quantum de pena aplicado e o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 44 do CP.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: (i) prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV), na razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo juízo da execução, com realização preferencial aos finais de semana ou outro horário que não atrapalhe o labor do acusado; e (ii) na interdição temporária de direitos, consistente na impossibilidade de que a ré deixe a comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem comunicar ao juízo.

9.6. Em razão da substituição, inviável a aplicação do art. 77, do CP.

Diante do exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR a acusada ROSIMARA IZABEL DE SIQUEIRA, devidamente qualificada, à pena de 01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro dias) dias-multa, por considera-lo como incurso no crime previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, nos termos do art. 44 do CP, substituo a pena, por duas restritivas de direito, consistentes em: (i) prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV), na razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo juízo da execução, com realização preferencial aos finais de semana ou outro horário que não atrapalhe o labor da ré; e (ii) na interdição temporária de direitos, consistente na impossibilidade de que a ré deixe a comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem comunicar ao juízo.

Custas pelo acusado, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade que lhes sejam deferidas.

Considerando que a sentença não tem o condão de alterar de maneira imediata a situação processual da parte, mantenho a situação em relação as cautelares, nos termos da decisão de fls. 35-38.

Serve a presente decisão como ofício/mandado/intimação.

Nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais.

Fixo honorários no valor de 100% da tabela do convenio OAB/Defensoria, em favor da defensora.

Expeçam-se as guias e certidões necessárias.

Após o trânsito em julgado:

- i. Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- ii. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;
- iii. Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.
- iv. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;
- v. Expeça-se guia de execução penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se."

Cientificados da sentença, o representante do Ministério Público disse que se conformava e desistia do prazo recursal. Por sua vez, o defensor da ré manifestou interesse em recorrer. Então, pelo MM. Juiz foi deliberado: "Homologo a desistência do prazo recursal com relação ao Ministério Público. Certifique-se o trânsito em julgado. Recebo o recurso de apelação, saindo o defensor da ré intimado do prazo legal para apresentação das suas razões. Após, abra-se vista dos autos à parte contrária para apresentação das contrarrazões. Ao final, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com as nossas homenagens. Saem os presentes intimados".2.- se houver testemunhas da Defesa: Nada mais havendo, foi encerrada a audiência, lavrando este termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, (Guilherme Henrique Garcia Ribeiro Camargo), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA